

1500863-23.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... dinheiro sem justificativa, a existência de petrechos utilizados no tráfico, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500863-23.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500863-23.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085184/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23918542 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

869/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2085184 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 869/22/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTERNEI DOURADO MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

VALTERNEI DOURADO MELO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 2022, por volta das 14h40min, na Rua José Zacharias, nº 139, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca, o acusado guardava, para comercialização com terceiros, aproximadamente 37,16kg (trinta e sete quilogramas e cento e sessenta gramas) da droga cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, Valternei guardava em sua oficina mecânica e no veículo GM/Celta, placas IRN-0C81, a droga acima descrita, destinada à comercialização ilegal. Na data acima, policiais militares receberam informe de movimentação suspeita do referido veículo GM/Celta na área rural da cidade de Iracemápolis, e em diligências encontraram o automóvel abandonado num canavial, sendo localizados no seu interior dois tijolos de crack.

Posteriormente, em patrulhamento nesta cidade de Limeira, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, outra equipe de policiais militares abordou Valternei e outros dois indivíduos (Rafael dos Prazeres e Francisco Fernando Paulino), e em revista pessoal, encontraram com o denunciado a quantia de R\$3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais) em espécie.

Ao ser informado sobre o encontro do veículo com droga, Valternei confirmou a propriedade do automóvel, alegando que ele havia sido roubado, e informalmente aos policiais indicou que havia mais drogas em sua oficina mecânica situada nas proximidades.

Lá chegando, Valternei ingressou com os policiais na oficina e mostrou onde estava guardada a substância, sendo encontrados mais 35 tijolos de crack, além de balança de precisão, facas com resquícios de droga e uma porção esfarelada sobre uma mesa. O denunciado informou aos policiais que guardava a droga para terceira pessoa e em contrapartida receberia a quantia de dois mil reais.

Ato contínuo, Valternei foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, quando então os policiais receberam o chamado do locador da oficina (Gabriel Lemes da Silva), dizendo ter encontrado no local uma sacola com mais 7 tijolos de crack, que também foram apreendidos.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime (fls. 15/16).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 170/187).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 311/317) e da Defesa (fls. 319/326).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Aprecio a preliminar levantada pela Defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio

legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. O contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da Polícia Militar.

Revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela Defesa foi precedida de abordagem prévia do acusado na via pública. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em Iracemápolis quando receberam informação de movimentação suspeita do automóvel do denunciado, encontrado abandonado num canavial com dois tijolos de crack em seu interior.

Em patrulhamento na cidade de Limeira, houve abordagem do acusado e outras duas pessoas, encontrando em poder do denunciado três mil e quinhentos reais em dinheiro. Indagado a respeito do automóvel, o denunciado disse que era de sua titularidade e havia sido roubado, confirmando aos guardas que havia mais drogas na sua oficina mecânica localizada ali nas proximidades.

No estabelecimento comercial, o acusado ingressou com os policiais e mostrou onde guardava 35 tijolos de crack, além de balanças de precisão, facas com resquícios de droga e uma porção esfarelada sobre a mesa. Indagado mais uma vez, ele confirmou a guarda das drogas para terceira pessoa, recebendo para tanto dois mil reais.

Em razão desses fatos, houve buscas no interior da oficina (entrada franqueada pelo morador) e os agentes públicos localizaram diversas porções de crack. Posteriormente, o locador da oficina Gabriel encontrou mais sete tijolos de crack no estabelecimento comercial, entregando aos policiais.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da Polícia Militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel comercial de propriedade do denunciado, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema

280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - CRIME - FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

“Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE nº 603.616-AgR/RG - Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravamento regimental não provido”. (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

“AGRAVAMENTO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVAMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária - soberana quanto à matéria fático-probatória - entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravamento regimental desprovido”. (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

“Penal e processual penal. Agravamento regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da

ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

A respeito do consentimento dos moradores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP (Julgamento: 02/12/2021. Publicação: 06/12/2021), reafirmou a tese fixada no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma decisão, o Ministro Alexandre de Moraes anulou o venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) que exigia consentimento do morador comprovado por documento escrito da diligência policial e gravação audiovisual, eis que tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei, que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Embora a Defesa sustente que a versão judicial do acusado confirmaria a tese de que houve entrada forçada em domicílio, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais militares prestados na fase do inquisitivo e do contraditório, que se mostraram firmes e uníssonos quanto ao consentimento do morador, como adiante se verá.

A conduta do acusado, como mencionada na denúncia, de guardar entorpecentes para entrega a consumo de terceiros, caracteriza o delito de tráfico de drogas. É prescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a venda a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

O comércio ilícito de drogas tem na clandestinidade uma de suas principais características, o que dificulta a sua repressão. Os meios usuais de prova (testemunhal e documental) quase sempre se revelam pouco concludentes.

Logo, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos em falta de consentimento dos moradores como pretende a combativa Defesa.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/30), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 163/166 e 167/169), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o réu disse que tem 46 anos. É pintor e funileiro. Desconhece as drogas. Estava na oficina trabalhando. Por volta das onze horas da manhã viu uma pessoa pulando o portão e o rendendo. Pisou em cima da sua cabeça. Mais duas pessoas ingressaram. Foi jogado dentro de um cômodo e trancado. Viu que o portão abriu e bateu. As pessoas foram embora. Quebrou a porta e saiu. O seu carro Celta foi roubado. Não viu ninguém na rua. Foi até as imediações do mercado Enxuto. Pegou carona com um conhecido e foi até a garagem de Rafael, presta serviços a ele de funilaria e pintura, assim como o rapaz que estava junto. Comprou o carro e iria fazer boletim de ocorrência de furto. Foram pegar as câmeras, ninguém quis dar informação. Foram abordados pela viatura policial. Tentou explicar a ocorrência aos guardas. Os policiais não paravam de fazer perguntas, sua pressão subiu, passou mal. Disse a eles onde morava. Os policiais quiseram ir até a oficina que ele morava. Não tinha chave porque o automóvel foi roubado. Dois policiais saltaram o muro. Foi algemado. Nunca falou que as drogas eram de sua propriedade. Só depois é que esses entorpecentes apareceram. Não sabe dizer como essas drogas apareceram. Não viu a feição dos roubadores, não os conhecia. Não viu os policiais ingressando com drogas no local. Conhecia um guarda de vista, mas não tem qualquer desavença com ele. Alugava o imóvel de Gabriel e ficou sabendo do depoimento dele na delegacia. Tinha três mil e quinhentos reais em dinheiro. Não entendeu a razão do dinheiro não ter sido roubado. Não chegou a entrar na oficina com os policiais. Trancou o local antes de sair. O portão foi aberto pelos bandidos. Não indicou onde estavam os entorpecentes. Trabalha como funileiro há 22 anos. Não passava por dificuldades financeiras. Não tem contato com organizações criminosas (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral.

O policial militar Ivan Dias de Jesus contou que estava com sua equipe em serviço fazendo patrulhamento pelo bairro Nossa senhora de Fátima. O Copom jogou ocorrência de que um automóvel Celta de cor prata havia sido abandonado por quatro pessoas perto de Iracemápolis. Intensificaram o patrulhamento. Na rua em questão viram três pessoas defronte a uma residência, próximo da esquina. O que chamou a atenção é que Rafael é conhecido dos meios policiais. O acusado estava com o nariz lesionado e isso chamou a atenção. Em busca pessoal nada localizaram, salvo elevada quantia em dinheiro. O acusado tinha em seu poder três mil reais, assim como os demais abordados. As pessoas foram separadas. O réu disse ter sido vítima de roubo por três pessoas que roubaram o automóvel Celta. Francisco e Rafael foram chamados para localizar imagens das câmeras e apontar algum automóvel envolvido. Uma viatura de Iracemápolis foi até o local indicado como abandonado e no interior do automóvel os policiais localizaram tijolos de crack. Passaram a questionar o acusado a respeito da situação da droga encontrada no seu automóvel. Francisco falou que estava de carro estacionado na mesma rua, defronte a uma oficina. O acusado dizia ora que morava com a mulher no bairro, ora que morava na oficina. Foram com os três abordados até a oficina. O réu ficou nervoso ao se aproximar do veículo Fiat Palio, que é de propriedade de Francisco, e nada de ilícito foi encontrado. Perguntou ao réu a respeito das drogas no Celta e foi aí que o acusado disse ser dele aquelas drogas. Na oficina o réu disse que havia mais entorpecentes. A entrada foi autorizada e foi ele quem indicou onde estavam os entorpecentes. Localizaram trinta e cinco tijolos em um cômodo e havia adesivo dos Simpsons nas embalagens. Também tinha balança de precisão, facas com resquícios de droga, embalagens com crack fracionado. Indagado mais uma vez, o acusado disse que o roubo se deu quando fechava a oficina e ele foi jogado no chão pelos roubadores. O local foi periciado. O acusado comentou na delegacia que receberia dois mil reais para armazenar essa droga no interior da oficina e assumir a propriedade dos entorpecentes. Gabriel, responsável pela oficina, teria ingressado no local e encontrou mais sacolas com

quantidade de drogas. Essa sacola de droga indicada por Gabriel não estava no local no momento em que lá estiveram. Notou que o acondicionamento era diferente e dava ideia de que aquela droga encontrada por Gabriel havia sido desenterrada. Não conhecia nenhum dos abordados e sua equipe não foi até o local do veículo Celta. Quem voltou posteriormente a oficina foi o policial Ramos a pedido de Gabriel. Ficou sabendo que Gabriel ouviu barulhos vindo do interior da oficina. Confirma que os entorpecentes tinham a imagem do desenho Simpsons e acredita que é um modo de agir de facção criminosa local, para que as drogas não sejam desviadas. O acusado autorizou o ingresso na oficina após ele dizer que o automóvel era de sua propriedade e que drogas foram encontradas no interior daquele veículo. Foi o acusado quem mencionou a existência de mais drogas no interior da oficina. O local não estava trancado com cadeado, o portão tinha uma tranca e o acusado mostrou a eles onde havia a quantidade maior de drogas. Tiveram que transpor e a porta foi destrancada, o réu indicou o local e foi colaborativo, foi o próprio réu quem indicou onde estavam os entorpecentes (mídia).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo disse que a ocorrência foi inusitada. Em patrulhamento pelo bairro o Copom irradiou ocorrência de atitude suspeita de automóvel Celta deixado em posto de combustível perto de Iracemápolis. Quando fizeram a conversão na rua indicada, viram três pessoas. Um deles era conhecido dos meios policiais. Fizeram abordagem. Fez busca pessoal nos três. Encontraram dinheiro em poder deles. O acusado tinha em seu poder três mil e quinhentos reais. O réu tinha um ferimento no nariz, isso chamou a atenção. Indagado, ele disse ter sido vítima de roubo. O acusado não acionou a polícia e deu versões evasivas. Rafael e Francisco iriam ajuda-lo na procura de automóvel. A viatura policial compareceu ao local do encontro do automóvel e no seu interior foram localizados dois tabletes de crack. Indagado mais uma vez, ele confirmou ser dono do automóvel e das drogas. O acusado deu mais de um endereço. Ele disse que na sua oficina havia mais drogas. A entrada foi franqueada. Havia um cômodo e no local indicado encontraram um saco contendo trinta e cinco tabletes de crack com adesivo do Simpsons, assim como balança de precisão e faca. O acusado, Francisco e Rafael foram até o distrito policial. Depois receberam ligação de Gabriel pelo 190 dando conta de encontro de outras sacolas contendo mais drogas com resquícios de terra. Achou tudo muito estranho porque fizeram vistoria no local. Essa sacola apareceu posteriormente. O acusado aludiu a necessidade financeira, daí a razão dele armazenar drogas para terceiros. Ele iria ficar de um dia para outro com aquele entorpecente. Não foi dito o valor que iria receber. O réu franqueou a entrada e apontou onde estavam as drogas. Também localizaram um pote plástico contendo crack. Não o conhecia até então. Rafael era envolvido em crimes. Foi o sargento Ramos que retornou com as drogas posteriormente, era diferente daquelas que foram encontradas inicialmente (mídia).

O policial militar Gilson Ramos da Silva disse que participou da ocorrência mais tarde. Por volta das 21 horas, veio uma ligação 190 dizendo que Gabriel encontrou dentro da oficina uma certa quantidade de drogas. O local era alugado. O entorpecente estava debaixo de uma mesa, no mesmo local que foi periciado. Havia sete tijolos de crack, mas envolta em plástico marrom. Gabriel foi ouvido na delegacia. Havia marcas de terra nessa droga. Chegou depois e não viu qual a versão fornecida pelo réu (mídia).

O policial militar Clinger Santos Moreira de Vasconcelos contou que o Copom irradiou o automóvel Celta de cor prata. Fizeram buscas nas imediações e localizaram o veículo dentro do canavial, aberto e sem chaves. Dentro do carro localizaram dois tijolos de crack. Passaram essa informação ao Copom. Não localizaram a chave do automóvel. Não participou de diligências junto à oficina e nem com o réu. As drogas estavam embaixo do banco de passageiro. Não se recorda da cor da embalagem. Não conhece Limeira e não sabe a distância da oficina até o automóvel encontrado (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Gabriel Lemes da Silva contou que tem relação de propriedade com a oficina ocupada pelo acusado. O imóvel é da sua esposa e a locação já transcorria por quase um ano e meio. Não tinha qualquer desconfiança do acusado. Não tem intimidade com o réu. Não imaginava o que acontecia na oficina. Estava na sua casa quando os guardas encontraram drogas. Os guardas vieram perguntar a ele respeito do roubo do automóvel. Tinha chegado do serviço. Depois de meia hora da primeira vez viu os guardas comemorando o encontro de drogas na oficina. Na primeira vez que eles foram nada havia ocorrido. Na segunda vez o acusado estava algemado. Na primeira vez o réu estava em pé e tranquilo, sem algemas. Não chegou a entrar na oficina. Quando retornou da Unimed não havia mais ninguém. Foi aí que apagou a luz e fechou o portão da oficina. Lá localizou mais uma sacola de drogas dentro de um quartinho escuro. Sua esposa ligou para a polícia e os policiais retornaram para levar embora aquela droga. O local é um terreno. O cheiro da sacola era muito forte. Prestou depoimento na polícia. Não pode dizer se no meio tempo alguém entrou e saiu da oficina. Chegou a ouvir barulhos mais tarde, depois que voltou da delegacia. Viu marcas de pé no muro da oficina, não sabe se alguém iria buscar as drogas que achou. O local era uma oficina e nunca viu nada de anormal, o acusado pagava o aluguel, às vezes atrasava, e sabe que ele morava no local. O automóvel do réu era um GM Celta prata. O portão grande estava trancado com cadeado, pulou o portão, mas o portãozinho estava aberto. O réu vivia de uma forma mais simples. A rotina do acusado era de trabalhar como funileiro. Nunca viu movimentação estranha (mídia).

Pois bem.

Pelo teor da prova oral colhida, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando receberam informação de movimentação suspeita do automóvel do denunciado na área rural de Iracemápolis, encontrando-o abandonado no canavial e tendo em seu

interior dois tijolos de crack.

Após, em patrulhamento na cidade de Limeira, o réu e mais duas pessoas foram abordadas, sendo localizada em poder dele a quantia de três mil e quinhentos reais. Indagado, o acusado confirmou a propriedade do automóvel, mas informou ter sido vítima de roubo. Informalmente ele indicou aos policiais a existência de drogas em sua oficina mecânica.

No local indicado, com a entrada franqueada, foram localizados mais trinta e cinco tijolos de crack, além de balanças de precisão, faca com resquícios de droga e uma porção esfarelada sobre uma mesa. Indagado mais uma vez, ele informou aos guardas que guardava entorpecentes para uma terceira pessoa e receberia dois mil reais para tanto. Após ser preso, o locador da oficina Gabriel entregou mais uma sacola contendo mais sete tijolos de crack.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), a conduta do acusado quando da prisão, as circunstâncias da abordagem, o encontro de dinheiro sem justificativa, a existência de petrechos utilizados no tráfico, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a

quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que faziam patrulhamento de rotina e a prenderam em flagrante delito.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem".

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu foi flagrado com grande quantidade de drogas (trinta e sete quilogramas e cento e sessenta gramas de cocaína na forma de crack, em tijolos), havendo em sua embalagem identificação de organização criminosa (Simpsons), como aludido pelos policiais militares, com apreensão de vasta quantia em dinheiro sem qualquer justificção e petrechos utilizados na traficância ilícita, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio (STJ, Tema 1154, REsp 1963433/SP, REsp 1963489/MS e REsp 1964296/MG, Ministro João Otávio de Noronha).

No caso em tela, todavia, a quantidade e a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa, na medida em que consta nas embalagens em que estavam armazenadas as porções do entorpecente inscrições alusivas a determinada facção criminosa, com encontro de vasta quantia em dinheiro (cf. STJ, AgRg no HC n. 612.613/SP, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022; AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VALTERNEI DOURADO MELO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

P.R.I.

Limeira, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA